

1501552-38.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... - pela inaplicabilidade da lei de crime hediondos a hipóteses de tráfico privilegiado, como o presente caso:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA .1. O tráfico de entorpecentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

1501552-38.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

1501552-38.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIELA MEL OLIVEIRA MEDEIROS DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

GABRIELA MEL OLIVEIRA MEDEIROS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, pois, conforme consta, no dia 08 de junho de 2021, por volta de 19h, na Rodovia Presidente Dutra, altura do KM 204, Jardim Joia, nesta cidade e comarca de Arujá, estaria trazendo consigo e transportava, 05 "tijolos" de maconha com massa líquida de 5110 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo narra a exordial acusatória, nas circunstâncias de tempo e local supracitadas, policiais rodoviários realizavam fiscalização de rotina na Rodovia Presidente Dutra e abordaram um ônibus da empresa Águia Branca que realizava a linha São Paulo/Rio de Janeiro. Durante a fiscalização, os policiais encontraram uma mochila com a denunciada, que ocupava a poltrona 23. Ao revistarem a mochila, os policiais localizaram 5 tijolos de maconha. Indagada, a denunciada admitiu ser a dona da mochila e informou ter recebido R\$ 2.000,00 para transportar a droga da cidade de São Paulo até a cidade do Rio de Janeiro. Auto de prisão em flagrante (fls. 01). Boletim de ocorrência (fls. 06/09). Auto de

exibição e apreensão (fls. 15/16). Laudo de constatação (fls. 11/14). Laudo definitivo (fls. 96/98). Folha de antecedentes (fls. 104/106), certidão criminal (fls. 188).

Concedida liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares substitutivas em 05/04/2022 (fls. 196).

A acusada apresentou resposta à acusação (fls. 109/122), sendo recebida a denúncia e designada audiência de instrução (fls. 139/141).

Sobreveio audiência, na qual foram ouvidas duas testemunhas e interrogada a ré (fls. 189 e 196/98).

Em sede de alegações finais orais, o Ministério Público postulou pela procedência da pretensão punitiva, nos exatos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, requer aumento com relação a quantidade de droga apreendida, nos termos do artigo 42 da Lei 11.346/06, observa que o aumento pode ser compensado tanto com a confissão, quanto a menor idade da relativa da acusada. Na segunda fase inexistentes atenuantes ou agravantes a serem aplicados. Disse ainda ser cabível a aplicação do artigo 33, §4º da Lei 11.346/06, podendo ainda ser substituída por pena restritiva de direitos.

Por sua vez, a defesa, em alegações finais escritos, requereu que em caso de procedência, fossem reconhecidas a primariedade da acusada, assim como, seus bons antecedentes, a aplicação do artigo 33, §4º da Lei 11.346/06 e a conversão da pena em restritivas de direitos.

Vieram-me os autos conclusos para prolação de sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva merece ser julgada procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudos periciais e prova oral.

A autoria delitiva segue a mesma sorte.

Passo à análise da prova oral colhida.

A testemunha Gilberto Maia Pimenta, policial rodoviário federal, narrou que estava realizando procedimento padrão na praça de pedágio de Arujá, abordando ônibus, pararam um ônibus com destino ao Rio de Janeiro, subiram três policiais e adentraram e procederam a entrevista com todos os passageiros, conversaram com a ré e de posse dela estava uma bolsa e quando abriram encontraram a droga. Disse, ainda, que a droga era maconha, tinha 05 tabletes, cerca de 05 quilos, informou ainda que questionada sobre as drogas, a ré firmou que alguém teria lhe dado, para levar até o Rio de Janeiro, e que iria ganhar certa quantia.

A testemunha Fabíola Cecília Yamamura, policial rodoviário federal, relatou que no dia dos fatos estavam efetuando abordagens em ônibus interestaduais, na praça de pedágio de Arujá, ocasião em que foi abordado o ônibus que fazia a linha São Paulo/Rio. Como de praxe adentraram no ônibus, procederam a entrevista dos passageiros e olharam as bagagens de mão, e ao se deparem com a acusada, ao perguntarem por sua bagagem, ela estava de posse de uma mochila, onde encontraram tabletes de maconha, momento em que confirmou ser de sua posse a mochila, e que estava fazendo a viagem para entregar a droga no Rio de Janeiro e que receberia dois mil reais por isso.

A ré Gabriela, disse ter 21 anos, não tem profissão e não trabalhava, estudou até a oitava série, é solteira tem um filho de 2 anos, não foi processada antes. Com relação aos fatos disse que recebeu uma ligação de um rapaz chamado Jonathan que lhe fez a proposta de fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, e como estava sem emprego aceitou, chegando no local ele lhe entregou a mochila e de lá foi para a rodoviária e pegou o ônibus com destino ao Rio de Janeiro, e lá iria entregar para

um rapaz chamado Bruno, com isso iria ganhar dois mil reais. Informou que Jonathan é um rapaz que morava na sua rua, conhecia ele e o mesmo falou que estava precisando de uma menina para fazer um trabalho pra ele, e como estava sem serviço e precisando de dinheiro, apareceu essa proposta e então resolveu ir.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A acusada confessou o cometimento do delito, afirmando que aceitou a proposta que lhe foi feita, para entregar a droga no Rio de Janeiro. Disse também que iria receber o valor de dois mil reais para fazer este serviço, corroborando, desta forma, o relato oferecido pelas testemunhas policiais ouvidas.

Com a acusada foi encontrada uma mochila contendo 05 tabletes de maconha com peso total de 5110 gramas.

Em delegacia, fls. 02/03, os policiais apresentaram o relato de como se deu a abordagem da ré, de forma harmônica com o que foi declarado em juízo. A ré deu a mesma versão apresentada em audiência (fl. 04).

Ainda, o exame toxicológico confirmou a natureza entorpecente das drogas localizadas (fls. 11/14 e 96/98).

Vê-se, assim, que a prova amealhada durante a instrução processual é suficiente para o reconhecimento do crime de tráfico de drogas pela acusada.

Recorda-se, no mais, que o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, de modo que se consuma com qualquer das outras condutas descritas no mencionado dispositivo legal, como, transportar, trazer consigo, guardar, ter em depósito, entregar a consumo e fornecer drogas, ainda que gratuitamente.

Nesse mesma toada:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE QUE A PROVA OBTIDA NOS AUTOS É ILÍCITA, E DE QUE O CRIME É IMPOSSÍVEL, POR NÃO TER CHEGADO AO DESTINO, QUE NÃO FORAM VENTILADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDUTA DE TRANSPORTAR OU TRAZER CONSIGO, COM O INTUITO DE FORNECER, AINDA QUE PARA GRATUITO CONSUMO ALHEIO, QUE SE SUBSUME AO TIPO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. [...] 2. "Transportar", "trazer consigo" ou "fornecer ainda que gratuitamente" substância entorpecente ilícita são São Paulo núcleos do tipo do delito de tráfico de drogas - crime de perigo abstrato, de ação múltipla e conteúdo variado, que se consuma com a prática de quaisquer das ações insertas no art. 33 da Lei Antidrogas. (HC 225555/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. em 09/12/2012).

Tratando-se de acusado primário (f.A. Fls. 35/36 e certidão de antecedentes fls. 188), deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois a ré ostenta bons antecedentes e inexistente nos autos comprovação suficiente de que se dedique a atividade criminosa.

No mais, inexistente qualquer causa excludente de ilicitude ou que isente o réu de pena, sendo a ação foi culpável, reprovável, pois a ré era (e ainda é) ao tempo da conduta imputável, tendo consciência da ilicitude de suas ações. Não há, portanto, qualquer causa excludente da culpabilidade.

Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de condenar GABRIELA MEL OLIVEIRA MEDEIROS DA SILVA, qualificada no autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, c.C. §4º, e art. 40, inciso V, tudo da Lei 11.343/06.

Apurada a responsabilidade penal, passo a dosar a pena.

Assim, verifico que a ré agiu com a culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar nesse sentido. Não há nos autos elementos concretos que permitam uma valoração da sua personalidade. A ré não ostenta maus antecedentes (fls. 104/106 e 188). O motivo do delito se constituiu pela obtenção do lucro fácil, que já é

punido pela própria tipicidade e previsão do delito. Nada há, em concreto, que desabone a sua conduta social. As consequências do crime não se mostraram de maior monta. As circunstâncias, por sua vez, são desfavoráveis à acusada, já que o fato envolveu a apreensão de considerável quantidade de maconha, embora se trate de droga, a princípio, de menor poder vulnerante, quando comparada com outras substâncias ilícitas. Diante dessa circunstância desfavorável, fixo a pena base em 06 (seis) anos, e 03 (três) meses de reclusão e 625 dias-multa, no menor valor legal.

Ausentes circunstâncias agravantes. Incidem a atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d" do CP, visto que foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ, e também a atenuante da menoridade, razão pela qual atenuo a pena fixando-a agora em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, no mínimo legal.

Presente a causa de aumento do tráfico interestadual, art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, aumentando a pena em 1/6, passando para 05 anos (cinco) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 583 dias-multa.

Incide, como já asseverado alhures, a causa de diminuição de pena do § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez que a ré é primária, não possuindo antecedentes, não havendo ainda provas suficientes de que se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, não tendo sido produzida pela acusação nenhuma prova de vínculo aprofundado e estável com o comércio espúrio, para cujo reconhecimento seria necessária a existência de prova cabal neste sentido.

Neste ponto, vale mencionar a manifestação de César Dário Mariano:

Presentes os requisitos previstos na norma a diminuição da pena é obrigatória, não ficando ao alvedrio do Juiz operar a redução ou não. Embora a norma empregue a expressão "as penas poderão ser reduzidas", não se trata de atividade discricionária do Juízo, mas de direito subjetivo do acusado. Aliás, a primariedade e bons antecedentes deverão ser demonstrados pelo acusado, ao passo que caberá ao Ministério Público o ônus de provar que o réu se dedica à atividade criminosa ou que pertence à organização criminosa. Não cabe ao réu a prova de fatos negativos, mas a quem alega, no caso, o Ministério Público.

(...) Dedicar-se a atividades criminosas pressupõe reiteração de condutas tipificadas como crime, ou seja, habitualidade no cometimento de delitos. Tal circunstância poderá ser demonstrada por meio de folhas de antecedentes criminais, certidões cartorárias, cópias de outros processos, testemunhas, ou seja, qualquer meio hábil a provar a vida criminosa do acusado. Como a norma não diz qual espécie de atividade criminosa poderá ser qualquer uma, desde que, obviamente, não se trate de delitos culposos, que pressupõem ausência de vontade.

A norma visa a impedir a redução da pena para aquele que de forma habitual e deliberada pratica qualquer espécie de crime. Com efeito, aquele que faz da vida criminosa seu modo de vida não é merecedor do redutor. (Silva, César Dário Mariano da Lei de drogas comentada / César Dário Mariano da Silva. -- 2. ed. -- São Paulo : APMP - Associação Paulista do Ministério Público, 2016).

Em sentido semelhante:

"A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena" (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).

Outrossim, conforme explanado anteriormente, a quantidade de drogas, por si só, não pode resultar na interpretação de que a ré faz do tráfico seu meio de vida ou integra organização criminosa. Nesse sentido, em complemento aos arestos já colacionados, seguem os julgados abaixo:

Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

I - A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante.

II - A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes.

III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal. Precedentes.

IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. (STF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 138.715 MATO GROSSO DO SUL.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. SÚMULA 7/STJ. CONTRIBUIÇÃO DO AGENTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NA CONDIÇÃO DE MULA. APLICAÇÃO DO REDUTOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Assentado pelo Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos, que inexistia prova da dedicação da acusada à atividade criminosa, a alteração desse entendimento enseja o revolvimento do conteúdo probatório dos autos, inadmissível em recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. No caso, conforme se extrai dos excertos, o Tribunal de origem, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, concluiu motivadamente pela aplicação do redutor no patamar de 1/3, tendo em vista que a atuação da ré era típica de 'mulas do tráfico', embora tenha sido apreendida com grande quantidade de drogas (33 kg de maconha). 3. O atual entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria é no sentido de que a simples atuação como "mula", por si só, não induz que o réu integre organização criminosa, de forma estável e permanente, não constituindo, portanto, fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor em sua totalidade, tratando-se de meras ilações, presunções ou conjecturas, até porque pode se tratar de recrutamento único e eventual (Precedentes.) 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1776471 MS 2018/0285250-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGENTE NA CONDIÇÃO DE "MULA". REDUÇÃO EM 1/3. PROPORCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a

quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos - 153 kg de cocaína - para elevar a pena-base em 3 anos e 4 meses acima do mínimo legal, o que não se mostra desproporcional. 3. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 4. A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/3, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Logo, devidamente motivada a escolha do patamar de redução, a alteração desse quantum é questão afeta à atividade discricionária do julgador, que só pode ser revista quando verificada sua desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 495680 SP 2019/0058485-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019)

Diante disto, cabível a redução à razão de 2/3, já que somente a quantidade de drogas não é elemento suficiente a afastar a minorante ou mesmo modular a fração do benefício. Demais, a natureza e quantidade da droga já foram consideradas por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais. Nesse sentido, o recente julgado do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA E, PORTANTO, NÃO SE PRESTAM PARA JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAR A FRAÇÃO DESSE BENEFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (RECURSO ESPECIAL Nº 1925096 - SP - RELATORA: MINISTRA LAURITA VAZ - Brasília, 02 de agosto de 2021). (grifos nossos).

Assim, diminuo a pena em 2/3, ficando a ré condenada à pena de 01 (um) anos e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão cumulada com 194 dias-multa, no mínimo legal, pena esta que torno definitiva.

Nesse contexto, à míngua de outras causas modificadoras, fica a ré GABRIELA MEL OLIVEIRA MEDEIROS DA SILVA, qualificada nos autos, definitivamente condenada por tráfico privilegiado à pena de 01 (um) anos e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão cumulada com 194 dias-multa, no mínimo legal, pena esta que torno definitiva.

Do regime inicial de cumprimento de pena e alternativas penais

O parágrafo 4º do art. 33 da lei 11.343/06 de forma louvável, admitiu em casos como o ora analisado, a possibilidade de redução da pena imposta ao acusado primário e de bons antecedentes em até 2/3. A previsão legal de uma causa de diminuição de pena nestas circunstâncias tratou de prestigiar da forma adequada o princípio constitucional da individualização da pena, reconhecendo uma situação fática que salta aos olhos do operador do direito: o de que traficantes eventuais, de bons antecedentes e que nunca se envolveram em organizações criminosas não podem ser equiparados aos grandes comerciantes de drogas, verdadeiros empresários do tráfico, responsáveis por manter toda uma rede articulada de produção e distribuição de drogas, auferindo grandes lucros da atividade e fomentando o cometimento de outros tantos delitos gravosos. Como se vê, são duas espécies distintas de criminosos a justificar tratamentos diversos pela lei penal.

Estranhamente, o próprio dispositivo legal supra aludido, de forma incongruente, negava expressamente a possibilidade de substituição da pena privativa em pena restritiva de direito, afastando-se, desta feita, dos parâmetros da

proporcionalidade e razoabilidade, e, como tal, do próprio princípio da individualização da pena que, de início, parecia pretender alcançar.

Não há dúvida, como mencionado alhures, que a reprovabilidade da conduta do traficante ocasional é menor do que a dos grandes traficantes de droga responsáveis por coordenar e alimentar a grande cadeia do tráfico ilícito de entorpecentes. Eis a razão pela qual a nova lei de drogas, de forma feliz, reconheceu a culpabilidade atenuada daqueles pequenos criminosos, permitindo uma razoável diminuição da pena que eventualmente lhe venha a ser imposta.

Todavia, a concretização da máxima da individualização da pena não se esgota na dosagem da quantidade de pena aplicada ao réu, mas também se funda na determinação de sua qualidade ou natureza. Se a culpabilidade do réu é de menor grau, sustentando a lei uma diminuição da pena imposta, não subsiste razão jurídica para obstar ao réu a concessão de benefícios penais condizentes com a sua menor culpabilidade.

A substituição da pena privativa por restritiva de direito é mecanismo salutar e consentâneo com os primados do Estado Democrático de Direito em que vivemos, sendo, em caso como ora apresentado, bastante a demonstrar a reprovação do Estado com relação à conduta perpetrada pela agente, evitando-se assim os males que o sistema carcerário acarreta, mormente no tocante a presos que cometeram pequenos delitos, como o ora acusado.

A vedação outrora inserta no art. 33, §4º da lei 11.343/06 que impedia a substituição da pena privativa imposta revelava-se incoerente e arbitrária, destoando dos preceitos constitucionais aos quais deve estar atrelada, motivo pelo qual deveria ter sua aplicação afastada. Aliás, tal providência é hoje desnecessária, uma vez que o Senado Federal, desde 16.02.2012, seguindo a linha da jurisprudência dos tribunais, resolveu por bem baixar a resolução nº 05/2012, suspendendo a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” constante do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, de modo que desde tal data, não subsiste mais qualquer empecilho legal à substituição da pena nos casos de tráfico privilegiado.

Também afastada deve ser a regra inserta no art. art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, por determinar o cumprimento inicial da pena imposta por tráfico de entorpecentes, sempre no regime fechado, pelas mesmas razões declinadas relativas ao dispositivo que vedava a substituição da pena.

Aliás, o próprio STF, já vem entendendo - além da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito - pela inaplicabilidade da lei de crime hediondos a hipóteses de tráfico privilegiado, como o presente caso:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO:

INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA .1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida. (HC 118533, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 16-09-2016 PUBLIC 19-09-2016

PENA REGIME FECHADO INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/1990.

A imposição do regime inicial fechado, prevista na Lei de Crimes Hediondos, é inconstitucional, considerado o princípio da individualização da pena. Precedente: habeas corpus nº 111.840, relator o ministro Dias Toffoli, julgado pelo Pleno em 27 de junho de 2012, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de dezembro de 2013. PENA TRÁFICO DE DROGAS SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DA LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006. A vedação à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, prevista na Lei de Tóxicos, é inconstitucional, ante o princípio da individualização da pena. Precedente: habeas corpus nº 97.256, relator o ministro Carlos Ayres Britto, julgado em 1º de setembro de 2010 pelo Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de dezembro imediato. PENA EXECUÇÃO REGIME DE CUMPRIMENTO. Não se tratando de réu reincidente, ficando a pena no patamar de 2 anos e sendo as circunstâncias judiciais positivas, cumpre observar o regime aberto e apreciar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos artigos 33 e 44 do Código Penal. (HC 129714, Relator(a):& Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 25-04-2017 PUBLIC 26-04-2017) (grifos nossos)

Esse mesmo entendimento vem sendo seguido pelo STJ, senão vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. LEGALIDADE. RECENTE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS E OBJETIVAS QUE RECOMENDAM A REDUÇÃO MÁXIMA. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO. PACIENTE PRIMÁRIA, CONDENADA À PENA QUE NÃO EXCEDE 4 ANOS, COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, entendeu que a possibilidade de início da execução da pena condenatória após a confirmação da sentença em segundo grau não ofende o princípio constitucional da presunção da inocência (HC n.126292, julgado no dia 17 de fevereiro de 2016). 3. No caso, a jurisdição das instâncias ordinárias encontra-se encerrada, porquanto na fase de admissibilidade do recurso especial interposto pelo paciente, sendo possível dar início à execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, sem que isso importe em violação do princípio constitucional da presunção de inocência. 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 5. No caso, verifico que a quantidade de entorpecentes não é expressiva para aplicar a fração em patamar diverso do máximo, com relevo para o fato de que a paciente era menor de 21 anos na data do fato, é primária, está grávida e já está inserida no mercado de trabalho. Assim, o redutor comporta aplicação em seu patamar máximo. 6. Em relação ao regime, cumpre asseverar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, com a redação dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, determinando, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, §§ 2º e

3º, c/c o art. 59, do Código Penal.7. No caso, o regime fechado, mais severo do que a pena comporta, foi fixado com base na hediondez do delito e na gravidade abstrata da conduta, fundamentos que não são considerados idôneos para fixar o regime mais gravoso. 8. Dessa forma, tratando-se de ré primária, condenada à pena privativa de liberdade não superior a 4 anos de reclusão, com a análise favorável das circunstâncias judiciais, a paciente faz jus ao regime aberto, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, assim como resulta cabível a conversão da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a sentença.(HC 391.679/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017)

Com efeito, seguindo a linha do que vem sendo sustentado pelos tribunais superiores, é, de fato, inevitável o reconhecimento da invalidade da norma proibitiva do início de cumprimento da pena em regime diverso do fechado pela violação ao devido processo legislativo, por não observar os comandos constitucionais de individualização da pena, porque, embora tenha cominado para o mesmo crime penas diversas em razão das condições pessoais dos acusados, com reconhecimento do excesso de penas ao primário, exige-lhe igual recolhimento ao cárcere, em regime fechado, a afrontar também o princípio da proporcionalidade. Nessa esteira, insta observar que o próprio Ministério Público pugnou pela fixação de regime diverso do fechado em suas alegações finais.

Com essa convicção, resultante da interpretação da norma infraconstitucional ao influxo da Constituição da República, embora haja uma circunstância judicial desfavorável, o regime inicial será o ABERTO, conforme determina o art. 33, e parágrafos, do Código Penal. Saliento que o regime inicial deve ser adequado à quantidade da pena, que no presente caso permite o estabelecimento do regime aberto, porque a acusada não é delinquente contumaz, como pode ser inferido das provas acostadas e folha de antecedentes.

A acusada permaneceu presa cautelarmente entre 09/06/2021 e 05/04/2022. Portanto, deixo de aplicar o disposto no §2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 12736/12, uma vez que mesmo considerado o tempo em que permaneceu custodiada, não haveria alteração do regime inicial do cumprimento de pena.

Atendidas as condições previstas art. 44, e incisos e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal. Sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano, aplico também a pena restritiva de direito consistente na prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo a entidades públicas ou privadas, a ser especificada pelo juízo de Execução, sem prejuízo do pagamento dos dias-multa já fixados.

Direito de recorrer em liberdade

Concedo à ré o direito de apelar em liberdade, tendo em vista a pena aplicada, o regime imposto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a serem aferidos para as medidas cautelares e a ausência de requisitos para a continuidade da segregação cautelar.

Ademais, ressalte-se que, segundo jurisprudência do STF, ainda que tivesse havido a fixação de regime semiaberto à acusada, o que não é o caso, de rigor se tornaria a concessão do direito de recorrer em liberdade. Acerca do assunto, confira-se o aresto abaixo colacionado:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA

SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 9. Pelo entendimento consolidado neste Supremo Tribunal Federal, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC n. 165.932, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 11.12.2018). Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não se admitindo sequer modulação da custódia cautelar para se adequar ao regime inicial menos gravoso. (...) Considerando-se que o magistrado de primeira instância fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, incabível a manutenção da prisão preventiva do paciente, que permaneceria fechado até a finalização do processo ou outra providência adotada. 10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva de Paulo Adriano Machado Rogério de Souza, se por outro motivo não estiver preso, e determino ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itaboraí/RJ examine a necessidade de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal. Oficie-se ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itaboraí/RJ, ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e ao Superior Tribunal de Justiça para, com urgência, terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, enfatizando que devem ter seguimento as ações, os recursos e os habeas em tramitação, nos termos da legislação vigente. (STF - HC: 182567 RJ - RIO DE JANEIRO 0088052-82.2020.1.00.0000, Relator: Min. CÂRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/03/2020, Data de Publicação: DJe-069 24/03/2020). (grifos nossos).

Disposições Gerais

Com fundamento no art. 58, § 1º, da Lei nº 11.343/06, inexistente controvérsia acerca da qualidade e quantidade da droga, autorizo a incineração, preservada pequena porção para eventual contraprova, com comunicação à Autoridade Policial. Após o trânsito em julgado da presente decisão condenatória, sendo mantida, determino:

- a) Lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados.
- b) Apuração dos valores das penas de multa aplicada ao sentenciado.
- c) Comunicação à Justiça Eleitoral que o sentenciado encontra-se com seus direitos políticos suspensos, face ao disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal.
- d) Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os réus a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.
- e) Se for o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(s) Defensor(es) nomeado(s) no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.
- f) Com fundamento no art. 58, § 1º, da Lei nº 11.343/06, inexistente controvérsia acerca da qualidade e quantidade da droga, autorizo a incineração, preservada pequena porção para eventual contraprova, com comunicação à Autoridade Policial. P.I.C.

Aruja, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA